

- **Procedimiento N°: EXP202404399 (PS/00276/2024)**

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 13/02/24, **D^a. A.A.A.** (la parte reclamante), presenta escrito de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La reclamación se dirige contra la entidad CALLBELL S.A.S. con documento de identificación extranjero (Francia): *****DOCUMENTO.1** (la parte reclamada), por la presunta vulneración de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI).

Los hechos que manifiesta la reclamante son los siguientes:

“Desde una interacción previa en la cual busqué resolver una incidencia técnica a través de su servicio de soporte, he estado recibiendo comunicaciones continuas a pesar de haber solicitado formalmente la cesación de las mismas. Es importante señalar que, aunque se confirmó la solicitud de darme de baja de su sistema, las comunicaciones persisten”.

Junto al escrito de reclamación, se acompaña pantallazos de los WhatsApp intercambiados entre la reclamante y la reclamada:

- **(A.A.A.):** Quería saber si había alguna novedad sobre el ticket o alguna forma de leer los contactos que llegan a Callbell.
- **(CALLBELL):** Estoy en eso (...), hace un rato ya se lo comenté desarrolladores encargados. Voy a seguir muy pendiente hoy. (...), me comentan los devs que no ven ningún error. Mira me dijeron que te pasara estas instrucciones...
- **(CALLBELL)** Hola cómo están? te habla B.B.B., paso para recordarles que tienen una factura pendiente de este periodo, les dejo un enlace...
- **(A.A.A.):** Hola, yo no soy de facturación. Por favor no me manden comunicaciones.
- **(CALLBELL):** Gracias por comunicármelo, ¿quién sería el encargado del área para dejarlo agendado como Finanzas?
- **(A.A.A.):** Yo no dispongo de la información. Por favor, borren mis datos.
- **(CALLBELL):** Hola, En Callbell hemos trabajado mucho los últimos meses para trabajar en agilizar el sistema de búsqueda. Hoy les traemos una nueva barra de búsqueda mejorada que te permite encontrar lo que necesitas en un instante. Ahora podrás disfrutar de una búsqueda más rápida, eficiente y con más parámetros de búsqueda.

Día 21 de noviembre:

- (CALLBELL): *Ahora puedes conectar múltiples números de WhatsApp páginas de Facebook o perfiles de Instagram a una sola cuenta en Callbell. Esto significa que puedes gestionar todas tus conversaciones en un solo lugar...*
- (A.A.A.): *Hola, ya he dicho que no me escriban más, y no me di nunca de alta por WhatsApp.*
- (CALLBELL): *Hola A.A.A.! ¿Como estas? Enviamos un masivo informativo y te sacamos de la base para el tema de Facturación en la empresa en la que trabajabas antes.*

Día 12 de diciembre:

- (CALLBELL): *Descubre el módulo de Bot Builder de Callbell: Nuestro producto ha evolucionado y estamos a punto de lanzar un nuevo módulo de bot...*

Día 14 de diciembre:

- (CALLBELL): *Estaremos en vivo a las 4 pm ARG/ 2 pm COL/ 1 pm MEX y queremos invitarte a que formes parte de este evento ...*

Día 15 de diciembre:

- (CALLBELL): *Si requieres asesoría personalizada para construir tu primer bot o descubrir las nuevas novedades de Callbell...*

Día 18 de diciembre:

- (CALLBELL): *Si requieres asesoría personalizada para construir tu primer bot o descubrir las nuevas novedades de Callbell...*

Día 12 de febrero:

- (CALLBELL): *Aprende como crear tu primer Bot de WhatsApp en nuestro evento en vivo...*

SEGUNDO: Con fecha 19/03/24, de conformidad con lo estipulado en el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, (LOPDGDD), por parte de esta Agencia, se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada para que procediese a su análisis e informase, en el plazo de un mes, sobre lo que se exponía en el escrito de reclamación.

El traslado se envió a la dirección, *****DIRECCIÓN.1**, la cual aparece como “Dirección de la Sociedad” en la “Política de Privacidad” de su página web: <https://www.callbell.eu/es/politica-de-privacidad/> y se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) mediante notificación postal internacional siendo devuelta a origen con la anotación de “destinatario desconocido”.

TERCERO: Con fecha 27/05/24, por parte de la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se dicta acuerdo de admisión de trámite de la reclamación presentada, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD.

CUARTO: Con fecha 08/07/24, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la LPACAP, por la presunta vulneración del artículo 21 de la LSSI, tipificada como leve en el art. 38.4.d) de dicha norma.

En el acuerdo de apertura se determinó que la sanción que pudiera corresponder, atendidas las evidencias existentes en ese momento y sin perjuicio de lo que resultase de la instrucción ascendería a un total de 5.000 (cinco mil euros).

La notificación de la incoación del expediente se practicó conforme a las normas establecidas en la LPACAP. Según certificado del Servicio de Correos el escrito de incoación de expediente enviado a la dirección, *****DIRECCIÓN.1**, fue entregado el día 06/08/24 mediante certificado internacional, según consta en el expediente.

QUINTO: Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la LPACAP y transcurrido el plazo otorgado para la formulación de alegaciones, se ha constatado que no se ha recibido alegación alguna a la incoación del expediente, en esta Agencia.

El artículo 64.2.f) de la LPACAP -disposición de la que se informó a la parte reclamada en el acuerdo de apertura del procedimiento- establece que si no se efectúan alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, cuando éste contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, podrá ser considerado propuesta de resolución. En el presente caso, el acuerdo de inicio del expediente sancionador determinaba los hechos en los que se concretaba la imputación, la infracción de la LSSI atribuida al reclamado y la sanción que podrían imponerse. Por ello, tomando en consideración que la parte reclamada no ha formulado alegaciones al acuerdo de inicio del expediente y en atención a lo establecido en el artículo 64.2.f) de la LPACAP, el citado acuerdo de inicio es considerado en el presente caso propuesta de resolución.

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

HECHOS PROBADOS

Primero: Se constata que tras una interacción previa entre la reclamante y la reclamada, se solicita por parte de la reclamante la cesación de las comunicaciones y así consta en los mensajes de WhatsApp intercambiados:

- **(A.A.A.):** *Quería saber si había alguna novedad sobre el ticket o alguna forma de leer los contactos que llegan a Callbell.*

- (CALLBELL): *Estoy en eso (...), hace un rato ya se lo comenté desarrolladores encargados. Voy a seguir muy pendiente hoy. (...), me comentan los devs que no ven ningún error. Mira me dijeron que te pasara estas instrucciones...*
- (CALLBELL) *Hola cómo están? te habla B.B.B., paso para recordarles que tienen una factura pendiente de este periodo, les dejo un enlace...*
- (A.A.A.): *Hola, yo no soy de facturación. Por favor no me manden comunicaciones.*
- (CALLBELL): *Gracias por comunicármelo, quién sería el encargado del área para dejarlo agendado como Finanzas?*
- (A.A.A.): *Yo no dispongo de la información. Por favor, borren mis datos.*

Segundo: Se constata que tras la solicitud hecha por la reclamada para que dejaran de enviarla comunicaciones vía WhatsApp las comunicaciones persistieron y así consta en los mensajes de WhatsApp intercambiados:

- (CALLBELL): *Hola, En Callbell hemos trabajado mucho los últimos meses para trabajar en agilizar el sistema de búsqueda. Hoy les traemos una nueva barra de búsqueda mejorada que te permite encontrar lo que necesitas en un instante. Ahora podrás disfrutar de una búsqueda más rápida, eficiente y con más parámetros de búsqueda.*

Día 21 de noviembre:

- (CALLBELL): *Ahora puedes conectar múltiples números de WhatsApp páginas de Facebook o perfiles de Instagram a una sola cuenta en Callbell. Esto significa que puedes gestionar todas tus conversaciones en un solo lugar...*
- (A.A.A.): *Hola, ya he dicho que no me escriban más, y no me di nunca de alta por WhatsApp.*
- (CALLBELL): *Hola A.A.A.! Como estas? Enviamos un masivo informativo y te sacamos de la base para el tema de Facturación en la empresa en la que trabajabas antes.*

Día 12 de diciembre:

- (CALLBELL): *Descubre el módulo de Bot Builder de Callbell: Nuestro producto ha evolucionado y estamos a punto de lanzar un nuevo módulo de bot...*

Día 14 de diciembre:

- (CALLBELL): *Estaremos en vivo a las 4 pm ARG/ 2 pm COL/ 1 pm MEX y queremos invitarte a que formes parte de este evento ...*

Día 15 de diciembre:

- (CALLBELL): *Si requieres asesoría personalizada para construir tu primer bot o descubrir las nuevas novedades de Callbell...*

Día 18 de diciembre:

- (CALLBELL): *Si requieres asesoría personalizada para construir tu primer bot o descubrir las nuevas novedades de Callbell...*

Día 12 de febrero:

- (CALLBELL): *Aprende como crear tu primer Bot de WhatsApp en nuestro evento en vivo...*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia.

Es competente para iniciar y resolver este Procedimiento Sancionador, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo establecido en el art. 43.1, párrafo segundo, de la LSSI y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la LOPDGDD.

La D.A. cuarta de la LOPDGDD establece, sobre el "*Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes*", que: "*Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes.*"

II. Síntesis de los hechos acaecidos:

Según la reclamante y así consta en la documentación presentada, desde que se puso en contacto con la reclamada para resolver una incidencia técnica a través de su servicio de soporte ha estado recibiendo comunicaciones comerciales vía WhatsApp a pesar de a pesar de no haberlas solicitado ni autorizado previamente.

III. Tipificación de la infracción cometida.

El hecho de que la reclamada envíe mensajes publicitarios a la reclamante sin que ésta, previamente los hubieran solicitado o expresamente autorizado, constituye una vulneración de lo establecido en el artículo 21 de la LSSI, pues establece lo siguiente:

"1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de estas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.”

IV.

Graduación de la sanción

La citada infracción del artículo 21 de la LSSI, se encuentra tipificada como leve en el art. 38.4.d) de dicha norma, que califica como tal, *“El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave”*.

A tenor de lo establecido en el artículo 39.1.c) de la LSSI, las infracciones leves podrán sancionarse con multa de hasta 30.000 €.

Por su parte, el artículo 40 de la LSSI establece los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones: *“La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes criterios:*

- a) La existencia de intencionalidad.
- b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
- c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
- d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
- e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
- f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
- g) La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.

Se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con el siguiente criterio agravante, que establece el art. 40 de la LSSI:

- La existencia de intencionalidad (apartado a), ya que, pese a solicitar la reclamante que dejaran de enviarla más comunicaciones vía WhatsApp, la

reclamada siguió enviándola comunicaciones comerciales por este medio hasta en cinco ocasiones más.

Con arreglo a dichos criterios, se estima adecuado imponer una sanción de 5.000 euros (cinco mil euros), por la infracción del artículo 21.1 de la LSSI, al enviar mensajes publicitarios a la reclamante, incluso después de que ésta hubiese solicitado que no volvieran a enviarla más comunicaciones comerciales.

De acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER a la entidad CALLBELL S.A.S. con documento de identificación extranjero (Francia): ***DOCUMENTO.1, por la infracción del artículo 21 de la LSSI, tipificada como leve en el art. 38.4.d) de la citada norma, una sanción de **5.000 euros (cinco mil euros)**.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad CALLBELL S.A.S.

TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva una vez sea ejecutiva la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida ***Nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000***, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.6 de la LOPDGDD), y de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.